

1500185-76.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, além de ter realizado campanhas em dias anteriores e da existência de ordem de serviço para investigar o réu.

Portanto, considera-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na diligência policial, desencadeada por denúncia de tráfico. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar prisão em flagrante, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500185-76.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500185-76.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Gutierrez Sant Ana

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu MARCELO GUTIERREZ SANT ANA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 19h20min, na Rua Anita Garibaldi, nº 28, Jardim São Manoel, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, trazia consigo droga (cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 02/02/2022 (fls. 102/113)

Regularmente notificado (fls. 226), o réu apresentou defesa prévia (fls. 158).

A denúncia foi recebida em 09/03/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual por meio de videoconferência (fls. 164/167).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez,

alegou, em preliminar, ilegalidade por ausência de mandado de busca domiciliar. No mérito, pugnou pela absolvição do réu por fragilidade probatória. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do crime imputado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, conversão da pena em restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegalidade suscitada pela defesa, porquanto não há qualquer nulidade em razão da ausência de mandado de busca e apreensão domiciliar quando há situação de flagrante delito, como ocorreu no caso presente. É que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República permite que se entre na residência sem mandado quando houver flagrante delito (neste caso, a traficância), não havendo constrangimento ilegal neste particular:

"Art. 5º.

(...)

XI. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Assim, não há que se falar em nulidade na busca e apreensão realizada na casa do réu, pois demonstrada a situação de flagrância, haja vista que o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro. E, havendo flagrante delito, existe permissivo constitucional para a invasão domiciliar desprovida de autorização judicial.

Nesse sentido:

"A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções, não protegendo o indivíduo em atividade criminosa no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente, a ausência da autoridade ou a falta do respectivo mandado, não maculam a busca e apreensão, inocorrendo, igualmente, nulidade da prisão em flagrante" (TJSP Habeas Corpus nº 68.215-3 Rel. Diwaldo Sampaio RJTJSP 115/257).

Desse modo, o ingresso dos policiais na residência do acusado, sem prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga, não tem o condão de tornar ilícita a prova. É que se tratando de crime permanente, desnecessário se faz a expedição de mandado de busca.

Ademais, no caso presente, os três policiais civis ouvidos em Juízo foram uníssomos em informar que haviam recebido denúncias anônimas anteriores dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, além de ter realizado campanhas em dias anteriores e da existência de ordem de serviço para investigar o réu.

Portanto, considera-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na diligência policial, desencadeada por denúncia de tráfico. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

No mesmo sentido:

"PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. RECONHECIMENTO.

INVIABILIDADE. O estado de flagrância autoriza a entrada dos policiais na residência sem necessidade de apresentação de mandado judicial. Exceção constitucionalmente prevista. Tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente e, como tal, implica na persistência do estado flagrancial no tempo. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estado de flagrância no caso concreto, com a visualização, pelos policiais, da prática de atos de traficância pela ré, com apreensão de porções de droga ainda na parte externa do imóvel.

Afastada a alegada nulidade da prova. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500120-41.2020.8.26.0592; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento:

02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021).

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Corrupção. Nulidade. Prova ilícita. Busca e apreensão sem mandado judicial. Inocorrência. Busca domiciliar autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República. Tráfico de entorpecentes é crime permanente. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente caracterizadas. Pena corretamente aplicada e fundamentada. Regime de cumprimento de pena alterado do integral para o inicial fechado, em razão da superveniência da Lei nº 11.464/2007 (que deu nova redação ao artigo 2º e §§, da Lei n. 8.072/90). Preliminar rejeitada. Pedido revisional parcialmente deferido, tão-somente para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. (TJ-SP - RVCR: 9015719932005826 SP 9015719-93.2005.8.26.0000, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 15/09/2011, 3º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2011)"

"Tráfico - Ingresso em domicílio sem mandado judicial - Apreensão de droga - Crime permanente - Flagrante - Prova lícita. (TJ-SP - RVCR: 00205789620148260000 SP 0020578-96.2014.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015)"

No mérito, a pretensão é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), pelas fotografias (fls. 39/40), pelos laudos periciais de constatação provisória (fls. 42/46 e 47/51), pelos laudos de exames químico toxicológicos definitivos (fls. 154/156 e 198/200), pelos laudos periciais de objetos (fls. 189/191, 192/194 e 195/197), pelos comprovantes de depósitos judiciais (fls. 127 e 201), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação Rodrigo Oliveira Freitas, policial civil, disse que receberam denúncias do Ministério da Defesa da Mulher da Família e Cidadania versando que o Marcelo estava agredindo os pais que são idosos e traficando drogas. Em conversa com os pais eles não agrediram que eram agredidos. Mas o tráfico de drogas foi levantado e estava realmente acontecendo. Várias vezes montaram vigílias e na ocasião recebeu informação de que o réu havia saído para buscar drogas. O depoente ficou em vigília e em um terreno baldio perto da casa e os demais policiais ficaram dentro do carro. Quando entrou a Paula Juliane, conhecida nos meios policiais, tiveram a certeza. Em abordagem ao réu no banheiro da casa, encontrou uma porção grande de cocaína no bolso dele. O réu disse que havia jogado outra parte de droga pela janela do banheiro para fora. Encontrou uma balança e uma faca que estava suja de cocaína. A menina confirmou que estava no local para fazer um programa sexual em troca de cocaína. A menina confirmou que estava no local para comprar droga. O réu confirmou que havia adquirido as drogas por R\$ 1.800,00 e iria revender por três mil reais. Foi encontrada a quantia de R\$ 150,00 em poder do réu, mas ele não disse a origem. O réu já é conhecido nos meios policiais, já foi preso pelo mesmo crime, inclusive. Não foi filmada a entrada dos policiais. Tem filmagem do réu confessando que a droga era dele no local (cf. mídia).

A testemunha de acusação Luciano Pereira de Andrade, policial civil, disse que recebeu denúncias do Ministério de Direitos Humanos relatando que o réu praticava maus tratos contra os pais que são idosos, além de tráfico de drogas. Em pesquisas, descobriu que o réu já havia sido preso por tráfico de drogas. Marcelo residia na edícula na casa dos pais. Em diligências, notou-se uma movimentação no local. Na data do fato, o policial Rodrigo teve conhecimento que o réu teria buscado droga em outra cidade. Em campanha, o policial Rodrigo ficou próximo à residência enquanto o depoente ficou dentro do carro com o policial Misael. Chegou um homem com motocicleta na casa do réu que entrou e saiu muito rápido. Na sequência, chegou Paula, conhecida nos meios policiais, e lá permaneceu. Diante dos indícios de tráfico de drogas, decidiram ingressar na residência. Conseguiram abordar Marcelo dentro próximo ao banheiro. Em revista no réu, o policial Misael localizou no bolso da bermuda dele uma pedra de cocaína e uma quantia de R\$ 150,00. Havia uma hack no quarto e na gaveta foi localizada uma balança de precisão e uma faca com vestígios de cocaína. O réu confirmou que adquiriu a droga por R\$ 1.800,00 e iria fracioná-la

e posteriormente revender por três mil reais. Paula confirmou que estava no local para adquirir drogas. Foi localizada uma pedra de "crack" que havia sido dispensada pelo réu com as embalagens. Possivelmente a origem do dinheiro foi proveniente do comércio de droga para o rapaz da moto. O réu estava lúcido e conversou normalmente. O réu já era conhecido nos meios policiais por estelionato e crime relacionado ao tráfico de drogas. Afirmou que no mesmo dia que tiveram conhecimento que o réu foi buscar drogas que estiveram na casa do réu. A droga poderia ser revendida até por cinco mil reais. Não foi filmada a ação de ingresso dos policiais porque tudo foi muito rápido. Quando pararam na frente da casa o réu avistou e saiu correndo. Não havia mandado judicial. Mas havia ordem de serviço para investigar o réu diante das denúncias do Ministério recebidas (cf. mídia).

A testemunha de acusação Misael Domingos da Silva Junior, policial civil, disse que havia recebido duas denúncias Disque 100 de que Marcelo agredia os pais e traficava drogas. Realizadas campanhas no local, verificou grande movimentação de pessoas no local. Dado momento, o policial Rodrigo obteve a informação de um colaborador de que Marcelo teria buscado drogas em uma cidade vizinha e estaria naquele momento embalando drogas para o comércio de drogas. Diante disso, montaram uma campanha próximo ao imóvel. Por volta de 19h, chegou uma motocicleta com um indivíduo masculino e ingressou na casa de Marcelo e logo saiu. Na sequência, chegou Paula que ingressou no imóvel e não saiu. Resolveram realizar a abordagem no imóvel momento em que Marcelo estava saindo da cozinha e viu os policiais e correu. Em abordagem, localizou Marcelo que disse que havia dispensado uma porção de "crack" e embalagens plásticas. No bolso de Marcelo havia uma porção grande de cocaína pesando 50 gramas. Marcelo disse que iria embalar cada grama e revender. Na cômoda do quarto do réu, foi localizada uma balança de precisão e uma faca com resquícios de pó branco na lâmina. Paula confirmou que teria comparecido ao local para adquirir droga com Marcelo e trocaria por sexo com ele. Marcelo disse que iria obter um lucro de três mil reais com a venda da droga. Marcelo possui passagem por receptação e tráfico de drogas. Aparentemente o réu estava lúcido, não aparentava estar sob efeito de drogas, ele estava bem coerente com as palavras e não apresentou nenhuma reação após a abordagem. Iniciaram as campanhas por volta das seis e meia quando Rodrigo ligou, após receber a notícia de que o réu estaria embalando drogas. A campanha foi realizada no dia e também em dias anteriores. Teve uma filmagem onde o réu falou algo, mas não se recorda. Havia denúncia anônima e no momento da abordagem o réu correu da atuação policial. Pela quantia em dinheiro sugere-se que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de três porções de drogas (cf. mídia).

A testemunha comum Paula Juliana Ferreira Calado, ouvida somente em solo policial, declarou que "É usuária de drogas maconha, cocaína e crack. Conhece o autor há oito meses, pois mantinha relações sexuais com o mesmo à troca de drogas. Assim, o autor realiza a mercancia ilícita de drogas, sendo conhecido de seus amigos, no entanto, por não ter dinheiro, praticava o sexo com ele como moeda de troca para as drogas. Nesta data, chegou na casa do autor no final da tarde para manter com ele conjunção carnal em troca de 01 porção de crack e 01 porção de cocaína, dirigindo-se para o quarto. Desse modo, já sentada na cama do autor, policiais adentraram o local. Pôde presenciar quando os investigadores revistaram o autor e localizaram no bolso da frente da bermuda uma embalagem contendo cocaína. Também pôde ouvir o autor informando aos investigadores que tinha arremessado crack pela janela do banheiro" (termo de declarações de fls. 13).

Em seu interrogatório judicial, o réu MARCELO GUTIERREZ SANT ANA disse que tinha adquirido droga para seu consumo pessoal e de sua namorada Paula. Não tem conhecimento da balança de precisão e nem as embalagens plásticas. Tinha acabado de chegar com as drogas. Pagou oitocentos reais na cocaína e no "crack". Era uma embalagem apenas. Pretendia consumir em quinze dias. Está com Paula há nove meses. Usava a droga com Paula e era o réu que levava a droga para ela. Quando viu os policiais, correu para o banheiro porque ficou com medo. Não jogou a droga, deixou em cima da rack. Tinha cinco gramas de droga com o réu no seu bolso. Já foi preso antes pelo crime do estelionato. Trabalhava com sucata antes de ser preso e ganhava até três mil reais por mês. Tem uma filha de quatorze anos que mora com a mãe dela

em Mato Grosso. Buscou a droga perto de Presidente Venceslau. Nunca vendeu drogas porque sempre trabalhou. Os policiais chegaram dizendo que havia denúncias de tráfico de drogas. A droga estava no local. Afirmou que os policiais chegaram e invadiram a casa (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a negativa do réu não merece crédito, pois divergente do arcabouço probatório produzido, com nítida intenção de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito praticado. O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia ao réu e destinava-se à traficância. Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente: (a) a natureza e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 01 (uma) porção de cocaína pesando 68,43g (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 27/28; laudo provisório de fls. 42/46 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 198/200), bem como outra porção da mesma substância com massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas) (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 27/28; laudo provisório de fls. 47/51 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 154/156); (b) 01 (uma) faca apreendida (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 27/28 e laudo pericial de fls. 189/191); (c) 01 (uma) balança digital que continha resquícios da droga apreendida (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 27/28 e laudo descritivo fls. 192/194); (d) fragmentos de sacolas plásticas (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 27/28 e laudo descritivo fls. 195/197); (e) as circunstâncias do réu tentar se desfazer das drogas entorpecentes; (f) a existência de denúncias do envolvimento do réu com a prática do tráfico de drogas, conforme depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo.

Segundo a prova oral, os policiais civis receberam informações de que o acusado estaria utilizando sua residência como ponto de tráfico de drogas, fato que motivou a "campana" realizada para averiguação da informação. Certo momento, avistaram o acusado saindo da residência e no momento que este avistou os policiais, adentrou a residência para tentar se desfazer das embalagens plásticas e uma pedra de "crack" com massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas).

Durante a abordagem, foi apreendida em poder do réu, em sua bermuda, no bolso da frente lado esquerdo, uma embalagem que continha 68,43g (sessenta e oito gramas e quarenta e três centigramas) de massa líquida da substância "cocaína", bem como o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na sequência, os policiais encontraram sobre a cômoda do quarto, debaixo de uma gaveta, uma balança digital e uma faca de serra branca com resquícios de pó branco.

Pois bem, a notícia anônima ou de populares é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza. Se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles encontrassem o réu, no mesmo local, guardando substância entorpecente.

Não se trata de embasar uma condenação apenas em informação anônima, mas sim condenar quem, através dela, restou comprovado que efetivamente cometeu o crime. Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 154/156 e 198/200), comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem

eskorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'.

(Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, a versão dos policiais civis foi corroborada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 27/28) comprovando a apreensão das drogas e dos objetos utilizados para sua comercialização (faca, balança e fragmentos de sacola), pelos laudos periciais provisórios (fls. 42/46 e 47/51) e laudos definitivos da droga (fls. 154/156 e 198/200) que atestaram positivo para "COCAÍNA".

Nesse contexto, a julgar pela expressiva quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, a saber, 01 (uma) porção da substância "COCAÍNA" pesando 68,43g (sessenta e oito gramas e quarenta e três centigramas), além de 01 (uma) porção da mesma substância pesando 0,45g (quarenta e cinco centigramas) (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/28) e dos petrechos apreendidos (faca, balança de precisão e fragmentos de sacola) tradicionalmente utilizados na comercialização da droga, aliado à existência de denúncias anônimas de traficância por ele realizada, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse sido flagrado comercializando a substância entorpecente, o simples trazer guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas não afasta a

caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a cocaína que estava em poder do representado, cujo peso totalizava 68,88g (sessenta e oito gramas e oitenta e oito centigramas), era suficiente para a confecção de mais de 600 (seiscentas) porções individuais!

Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Com efeito, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, bem como em vista a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico.

Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28 ou artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pelos policiais em Juízo é firme o suficiente para se concluir que os petrechos (faca, balança e fragmentos de sacola) e o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) apreendidos em poder do réu eram oriundos do tráfico de drogas, conforme depoimentos dos policiais civis demonstrando que estavam em campanha e visualizaram o momento em que, anteriormente à abordagem, ingressou na residência um outro indivíduo de forma muito rápida, tudo levando a crer que o acusado teria vendido três porções ao indivíduo, razão pela qual deve ser declarado perdido.

Por fim, convém ressaltar que a versão do réu, durante seu interrogatório judicial, de que foi agredido pelos policiais não convence, pois o laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões corporais e os abusos eventualmente por ele sofridos não foram informados durante a audiência de custódia realizada (termo de fls. 102/113).

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de

rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta conduta social reprovável, haja vista que é contumaz na prática de delitos, inclusive contra o patrimônio, conforme se denota de sua certidão criminal de fls. 56/65 e Folha de Antecedentes de fls. 66/98, demonstrando que respondeu a vários processos criminais em diversas cidades do Estado de São Paulo (Dracena, Mirandópolis, Presidente Venceslau, Pederneiras, Panorama. Pereira Barreto), o que demonstra que o seu envolvimento com o ilícito não é esporádico, tudo a indicar que faz dos crimes seu meio de vida. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes, pois apresenta condenações com trânsito em julgado pelo crime previsto no artigo 155, caput do Código Penal (Autos nº 0004992-54.2001.8.26.0168 fls. 56/57, com trânsito em julgado no dia 10/11/2006), pelo artigo 171 do Código Penal (Autos nº 0005508-35.2005.8.26.0168 - fls. 57, com trânsito em julgado no dia 18/01/2011; Autos nº 0008344-78.2005.8.26.0168 - fls. 58/59; Autos nº 0004572-31.2004.8.26.0431 - fls. 60/61, com trânsito em julgado no dia 21/08/2006 e Autos nº 0009604-84.2006.8.26.0483 - fls. 62/63, com trânsito em julgado no dia 02/04/2009), pelo artigo 180 do Código Penal (Autos nº 1500406-93.2021.8.26.0168 - fls. 60, com trânsito em julgado no dia 09/03/2022) e pelo artigo 28 da Lei de Drogas (Autos nº 0009576-41.2008.8.26.0356 - fls. 60, com trânsito em julgado no dia 13/07/2009).

Igualmente, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, presente duas circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59, CP) e considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (01 (uma) porção pesando 68,43g e outra pesando 0,45g) o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu.

Assim, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, exaspero a pena-base em 1/2 (um meio), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papelotes de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência, pois o réu apresenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas (0004538-12.2018.8.26.0481 - fls. 62), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 09 (nove)



meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume as hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu é reincidente em crime doloso, possui maus antecedentes e conduta social reprovável. Ademais, no caso presente, o acusado guardava em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente cocaína, tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

Assim, torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, em razão da reincidência do réu, maus antecedentes e conduta social reprovável, aliado ao fato de que o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, bem como que o réu é reincidente em crime doloso, ostenta de conduta social reprovável e maus antecedentes, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu MARCELO GUTIERREZ SANT ANA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, fixados estes em 1/30

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 102/113), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendidas em poder do réu e em se tratando de réu reincidente em crime doloso, possuidor de maus antecedentes e conduta social reprovável, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e os petrechos apreendidos (faca, balança e dos fragmentos de sacola) em poder do réu (cf. autos de exibição e apreensão a fls. 27/28) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Se o caso, na forma do previsto no artigo 58, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo e informou em Juízo rendimento mensal inferior a três salários mínimos, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.

Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 05 de abril de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA